

1500048-56.2022.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... a primeira vez que abordou o casal por tráfico de drogas, mas era de conhecimento no meio policial que os réus estavam associados ao tráfico. Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente os denunciados. Além disso, nada há nada de concreto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz1@tjsp.jus.br

1500048-56.2022.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 23 de março de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500048-56.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS PERSIN RODRIGUES e outro

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 149/153) em face de JENIFER GOMES ESMERALDO e JONAS PERSIN RODRIGUES pela suposta prática dos seguintes fatos: "Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 13:00 horas, na Vicinal Roberto Romanini que faz ligação entres as cidades de Osvaldo Cruz e Salmourão, neste Município e Comarca, JENIFER GOMES ESMERALDO e JONAS PERSIN RODRIGUES, respectivamente qualificados a fls. 05/06 e 07, agindo com unidade de propósitos, em concurso, associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecente, visto que, com envolvimento da filha menor da denunciada, traziam consigo e transportavam 1040,1gramas de 'cocaína' em forma de 'crack' (02 porções), para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo de constatação provisória de fls. 17/19. Segundo o apurado, quando dos fatos, em patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o veículo Ford/Fiesta de placas AOK0A83, que trafegava no sentido a esta urbe, ocupados pelos denunciados, e deliberaram efetuar a abordagem, em razão das informações de que os meliantes estavam praticando tráfico de drogas. Durante a diligência, constataram que a denunciada estava no banco de trás do

automóvel com uma criança, identificada como sua filha, enquanto o denunciado era o condutor do veículo. Iniciadas as buscas, foi localizado sobre o bando traseiro, ao lado da denunciada e da criança um tablete de pasta base de cocaína. Já no assoalho sob o banco dianteiro do passageiro, foi localizada outra porção do mesmo entorpecente.

Foi dado voz de prisão e os denunciados foram conduzidos, com as drogas, a quantia de R\$61,00, em dinheiro, o veículo utilizado no crime e os celulares apreendidos com o casal, até a Unidade Policial para as providências pertinentes.

Assim, pela quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, bem como o desenrolar dos fatos acima descritos, e considerando as informações de que os denunciados estavam praticando o tráfico ilícito de drogas, evidente que os entorpecentes pertenciam aos denunciados e que estavam associados para sua mercancia ilícita."

A denúncia foi recebida em 01/02/2022 (fls. 155/156).

Houve a conversão do flagrante em prisão preventiva, porém, para Jenifer Gomes Esmeraldo foi substituída por prisão domiciliar (fls. 118/122).

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 192/196, Jenifer Gomes Esmeraldo; e fls. 199/204, Jonas Persin Rodrigues).

Não foi concedida absolvição sumária (fls. 205/206).

Foi impetrado, e, posteriormente, negado, pedido de Habeas Corpus em favor de Jonas Persin Rodrigues (fls. 229/243 e 245/247).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas, sendo, após, interrogados os réus (fls. 285/286).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 295/309).

A Defesa, por sua vez, a absolvição dos réus e, subsidiariamente, em caso de condenação, que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas (fls. 311/325).

Vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 10/13); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); auto de apreensão (fls. 14/15); laudo pericial (fls. 17/19); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria será analisada individualmente.

A testemunha Ademir Marcos Sarra, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que no dia dos fatos estavam transitando na vicinal Osvaldo Cruz - Salmourão e visualizaram o veículo dos réus. Sabiam que os réus já tinham cometido outros delitos. Em revista veicular, encontrou um tablete de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, no banco traseiro junto a ré e uma criança. No banco dianteiro, também foi localizada droga. O peso total era de aproximadamente 1,33 kg. Já havia denúncia anterior de tráfico de drogas com relação aos dois réus. A criança que estava no carro era de colo, tinha aproximadamente 1 ano de idade. Não recorda de ter apreendido dinheiro.

A testemunha Paulo César de Almeida, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que em patrulhamento visualizaram um veículo, já conhecido do meio policial, e decidiram abordar. Na abordagem pessoal nada foi encontrado. Contudo, em busca veicular, junto ao banco traseiro ao lado da cadeirinha da criança, foi encontrado um tijolo de pasta base de cocaína. Foi dado voz de prisão aos réus. No banco dianteiro também foi localizado mais drogas. Junto aos réus tinha uma criança de colo e foi acionado o conselho tutelar. O peso das drogas era aproximadamente de 1,16kg e 0,26kg. O veículo já era conhecido, pois dias antes, na residência do casal, o veículo se encontrava na garagem e os réus foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Foi a primeira vez que abordou o casal por tráfico de drogas, mas era de conhecimento no meio policial que os réus estavam associados ao tráfico.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente os denunciados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu Jonas Persin Rodrigues confessou os fatos. Disse que a droga era de sua propriedade. Não era pasta base, a cocaína já estava pronta para uso. A ré não sabia que a droga estava dentro do veículo. Enganou a ré, pois pensou que se tivesse uma mulher e uma criança no carro não seria abordado. Foi até a rodoviária de Birigui encontrar com o traficante. Este deu uma porção solta e entregou uma sacola com 1kg de cocaína. Jogou a droga dentro do carro e foi embora, pois estava desesperado, com medo de ser preso. O objetivo era vender o tablete, pois tinha prometido ao traficante arcar com os custos das drogas, que era por volta de R\$12.000,00. Encontrou o traficante por meio da internet. O tablete estava enrolado em uma roupa, e estava dentro de uma sacola. Do jeito que pegou, já colocou no interior do veículo.

Interrogada judicialmente, a ré Jenifer Gomes Esmeraldo negou os fatos. Disse que a droga não lhe pertencia. O tablete de cocaína não estava no banco traseiro. Não lembra de ter nenhuma sacola dentro do veículo, mesmo estando há 40 minutos dentro do carro, pois quando o réu retornou da rodoviária, estava dando mamadeira para o bebê. Não lembra onde foi encontrada a droga. Jonas a chamou para ir almoçar em Birigui. O réu parou na rodoviária e voltou com uma sacola de roupa. No retorno a Osvaldo Cruz, foram abordados e presos. Os policiais pediram para o réu descer do veículo, e revistaram o carro. Foram presos após a abordagem. A criança que estava no carro tinha 9 meses de idade na época dos fatos. Nunca se associou ao réu para praticar o crime de tráfico de drogas.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório.

Pois bem.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, a autoria está comprovada somente quanto ao réu Jonas, contudo, com relação à ré Jenifer as provas são duvidosas.

Com relação à ré Jenifer, é débil a prova incriminadora, de maneira que não há certeza se ela tinha conhecimento acerca da droga no interior da sacola.

Inexistindo, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia com relação a Jenifer, conduz à absolvição da ré, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser induvidoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

O réu confessou que a droga era de sua propriedade e que tinha comprado de um traficante na cidade de Birigui. Asseverou ainda que a droga estava envolta em uma roupa e no interior de uma sacola, sendo que, quando entrou no veículo, já colocou no banco traseiro e foi embora.

Ao que tudo indica o réu apenas se utilizou da ré e da criança para se evadir de uma eventual abordagem policial.

Destarte, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo

de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP -

APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de

Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de

Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A

Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias

entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (crack) consta no rol.

Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

No que tange ao crime de associação para o tráfico, a ação é improcedente.

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

Ademais, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto

Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de

Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-

83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR:

00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins,

Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

01/11/2018.

Não há nenhuma prova capaz de comprovar a associação. Os policiais abordaram os réus apenas pelo reconhecimento do veículo, sendo que não há nenhuma investigação em andamento acerca dos fatos.

Portanto, resta-se não comprovada a estabilidade e permanência da associação. Razão pela qual, com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, a acusação é improcedente.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do

crime de tráfico de drogas, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal. Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu Jonas praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (processo nº 0019570-61.2009.8.26.0032, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/05/13 - fls. 159/160; processo nº 0012650-33.2009.8.26.077, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/07/12 - fls. 160/161; processo nº 0012773-31.2009.8.26.077, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/01/12 - fls. 161; processo nº 0001518-56.2009.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/11/10 - fls. 161/163).

Outrossim, foi apreendido um tijolo de crack, totalizando 1.033,05 gramas, conforme auto de apreensão de fls. 14/15, sendo assim, a quantidade e a natureza da substância apreendida, haja vista o alto poder de dependência que esta droga gera, conduz ao aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

Razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: No momento da abordagem e da prisão em flagrante havia um bebê de 9 meses de idade dentro do veículo, além do tablete apreendido ter sido localizado ao lado da cadeirinha da criança.

O art. 40, VI da Lei de Drogas dispõe que as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

O verbo envolver traduz a ideia de trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto.

Portanto, há incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena provisória em 1/3, pela maior gravidade em razão da idade da criança, e fixo a pena definitiva em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa.

Inviável a causa de aumento prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Para que seja reconhecido o tráfico privilegiado é mister que os requisitos legais estejam presentes.

Contudo, o réu possui maus antecedentes (processo nº 0019570-61.2009.8.26.0032, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/05/13 - fls. 159/160; processo nº 0012650-33.2009.8.26.077, com trânsito em julgado para a Defesa em 04/07/12 - fls. 160/161; processo nº 0012773-31.2009.8.26.077, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/01/12 - fls. 161; processo nº 0001518-56.2009.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/11/10 - fls. 161/163), razão pela qual não preenche os requisitos legais.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em

14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR Jonas Persin Rodrigues como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 888 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

ABSOLVER Jenifer Gomes Esmeraldo dos crimes previstos nos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no art. 386, VII e III, do CPP, respectivamente;

ABSOLVER Jonas Persin Rodrigues do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no art. 386, III, do CPP.